

1503375-75.2021.8.26.0073

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: LEONARDO LABRIOLA FERREIRA MENINO

Comarca: Avaré

Foro: Foro de Avaré

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/02/2022

... do corréu Vinicus admitindo que praticou sozinho o tráfico de drogas revela, tão somente, mais uma tentativa inexitosa de livrar os réus Francisco e Nestor das imputações de tráfico, bem como reduzir significativamente sua pena almejando o reconhecimento do privilégio previsto no § 4º do art 33.

Nesse contexto, as versões dos réus, além de inconsistente e implausível de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Avaré

Foro de Avaré

1ª Vara Criminal

Rua Abílio Garcia, 527, Avare-SP - cep 18706-047

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1503375-75.2021.8.26.0073 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503375-75.2021.8.26.0073

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2219226/2021 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 19594262 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 2240/21/129 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 2219226 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 2219226 - DISE- DEL.SEC.AVARE, 2240/21/129 - DISE- DEL.SEC.AVARE, 066/2021 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Avaré

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRANCISCO HERNANDES NETO e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LEONARDO LABRIOLA FERREIRA MENINO

VISTOS.

FRANCISCO HERNANDES NETO, NESTOR FELIPE VALMOR STRINGHETTA e VINICIUS SEABRA DUARTE, já qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 c.c. art. 29 do Código Penal, sob a acusação de que, na noite de 12 de agosto de 2021, por volta das 19h10, na Avenida Professor Celso Ferreira da Silva, Jardim Europa II, neste

município e Comarca de Avaré, previamente ajustados e com unidade de desígnios, transportavam 25 (vinte e cinco) tijolos de maconha, com peso aproximado de 13.638,8 (treze mil, seiscentos e trinta e oito gramas e oitenta centigramas) e 06 (seis) porções de maconha, com peso de 6,2 (seis gramas e vinte centigramas), conforme laudo de constatação provisória a fls. 80/83, substância que causa dependência, o que fazia em desacordo com norma legal ou regulamentar (portaria 344/98 SVS/MS).

Auto de prisão em flagrante e demais peças do Inquérito Policial às fls. 01/192. Por ocasião da apreciação da prisão em flagrante houve a conversão em prisão preventiva (fls. 122/125). Mandados de prisão cumpridos a fls. 277/288. A denúncia foi oferecida em 26 de agosto de 2021 (fls. 196/199) e os réus, devidamente notificados a fls. 330, 332 e 334, apresentaram Defesa Prévia (fls. 294/300, 322/324 e 340/353). Não sendo o caso de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 20 de setembro de 2021, oportunidade na qual houve a designação de audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 362/366). Os réus foram citados a fls. 491, 493 e 495. Durante a instrução foram ouvidas três testemunhas de acusação, três testemunhas de defesa e os réus interrogados (fls. 500/501 e gravações audiovisuais).

Em alegações finais, o Ministério Público discorreu sobre toda a prova produzida e, ao final, pugnou pela procedência da ação a fim de condenar os réus nos exatos termos da denúncia (fls. 505/510). A douta defesa do réu Vinicius pugnou pela aplicação da pena em seu patamar mínimo legal, pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da lei de Drogas, pela fixação do regime inicial aberto e pelo direito de recorrer em liberdade (fls. 514/524). A defesa do corréu Francisco, por sua vez, pleiteou pela absolvição do réu e, subsidiariamente, pela fixação da pena em seu patamar mínimo legal, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 525/530). Por fim, a defesa do réu Nestor, pugnou pela absolvição do réu com fundamento no artigo 386, inciso VII do CPP. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleitou pela fixação da pena em seu patamar mínimo legal, pelo reconhecimento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 e fixação do regime inicial aberto (fls. 537/547).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e Decido.

Segundo a inicial acusatória, "na data dos fatos o denunciado FRANCISCO conduzia o veículo VW/Gol, placas JEX0440/Bauru-SP, estando VINICIUS no banco do passageiro e NESTOR no banco traseiro. No automóvel os denunciados transportavam 25 (vinte e cinco) tijolos de maconha no interior de uma embalagem térmica acondicionada atrás do banco do motorista e outras 06 (seis) porções da mesma droga no bolso da bermuda de VINICIUS, ocasião em que foram surpreendidos pela Polícia Militar em razão do forte odor de maconha proveniente do veículo. A quantidade de droga apreendida, sua forma de acondicionamento e as circunstâncias da prisão indicam que os entorpecentes se destinavam ao fornecimento e entrega ao consumo de terceiro". Pois bem, a meu ver, os fatos narrados comprovaram-se em juízo, merecendo ser julgada procedente a presente ação penal.

A materialidade do delito restou configurada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência a fls. 13/18, auto de exibição e apreensão (fls. 19/20), fotografias a fls. 51/76, laudo de constatação provisória dos entorpecentes a fls. 80/83, laudo toxicológico definitivo a fls. 179/184, bem como por toda prova oral produzida.

A autoria também é certa e indubitavelmente recai sobre os réus.

O policial militar Marcelo dos Santos Gambini, em juízo, contou "que, no dia dos fatos, avistaram os réus no interior de um veículo em atitude suspeita, razão pela qual efetuaram a abordagem. Contou que ao se aproximarem do automóvel, sentiram um forte odor de maconha, a qual acabou sendo localizada em um caixa térmica sobre o banco traseiro do motorista. Disse que havia 25 tijolos da droga. Falou que os acusados apresentaram versões divergentes. Contou que o réu Vinicius disse que a droga era sua, já o réu Nestor afirmou que a droga era do motorista do Uber, o réu

Francisco. Já o acusado Francisco disse que foi fazer uma corrida para os demais réus, que saiu de Bauru com destino ao Jardim Camargo, em Avaré, local conhecido como ponto de venda de drogas. Estima que o valor total das drogas seria de R\$ 15.000,00 a R\$ 20.000,00".

A testemunha Marlon Diniz Araujo, policial militar, judicialmente, reprisou a assertiva de seu colega, acrescentando que "com o réu Vinicius foram localizadas 06 porções de maconha já na Delegacia de Polícia".

A testemunha Diego Pires do Prado, policial militar, corroborou a versão de seus colegas policiais, afirmando "que todos os ocupantes do veículo esboçaram atitude suspeita ao avistar a viatura".

A testemunha de Defesa Cláudio Costa Pereira Júnior, disse "que conhece Francisco há anos, que é pessoa trabalhadora e que trabalhava em um posto de combustível e como motorista de UBER. Contou que Francisco tem família, que nunca viu ou ouviu o mesmo envolto com nenhum ato ilícito, sendo uma pessoa honesta e trabalhadora".

A testemunha de defesa Danilo Augusto Araujo Brito, disse "que conhecia Nestor da rua, pois moravam no mesmo bairro. Não sabe dizer nada sobre os fatos. Disse que o réu trabalhava como pizzaiolo. Conhece sua família e não sabe os veículos que eles possuem".

A testemunha de defesa Vilma Pereira Rosa falou "que conhece Nestor há muitos anos, conhece toda sua família. Trabalhava como pizzaiolo junto com sua família. Não soube do seu envolvimento com drogas".

O réu Francisco Hernandes Neto, em seu interrogatório judicial, negou a prática dos fatos que lhe são imputados na denúncia. Contou "que o acusado Vinicius pediu para fumar um cigarro de maconha em seu veículo, o que autorizou, pois não teria mais clientes depois. Falou que não conhece o cheiro de maconha porque nunca teve contato com drogas. Disse que foi contratado por R\$ 200,00 para fazer o trajeto Bauru a Avaré. Disse que pegou Vinicius e Nestor no Mary Dotta. Falou que não perguntou sobre o cheiro do cigarro de Vinicius porque achou constrangedor".

O réu Vinicius Seabra Duarte, em seu interrogatório judicial, admitiu a prática do tráfico de drogas. Disse "que conhece os demais réus do período em que estudaram juntos e que ficou com o contato do réu Francisco por ele ser Uber. Falou que estava precisando de dinheiro e que por isso aceitou transportar a droga até Avaré. Falou que convidou o réu Nestor acompanhá-lo mas que ele não sabia o que tinha na caixa térmica".

O réu Nestor Felipe Valmor Stringhetta, em seu interrogatório judicial, negou a prática do crime que lhe é imputado. Contou "que é usuário de drogas e que, no dia dos fatos, encontrou o réu Vinicius nas imediações de um estabelecimento em que foi comprar refrigerante. Falou que queria comprar maconha e perguntou para Vinicius se sabia quem tinha. Contou que Vinicius afirmou que possuía porções com ele e ofereceu para fumarem juntos. Disse que o réu Francisco trabalhava como Uber e que chegou ao local para uma corrida a pedido de Vinicius, momento em que foi convidado para acompanhá-los. Como no dia estava de folga resolveu aceitar e assim já fumaria o cigarro oferecido por Vinicius. Disse que acreditou que o cheiro da droga era proveniente de seu cigarro".

Pois bem, as provas colhidas em juízo apontam para a ilícita mercancia praticada pelos réus. A tipificação do crime de tráfico de drogas, in casu, extrai-se do local para onde os réus se dirigiam (bairro conhecido pelo comércio de drogas), das circunstâncias da prisão, da quantidade de droga apreendida (25 tijolos de maconha e 06 porções pequenas da droga), bem como do modo pelo qual estava acondicionada (escondida dentro de uma caixa térmica no interior de um veículo). Com efeito, verifico que a negativa oferecida pelos réus Francisco e Nestor não encontra respaldo nas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo de rigor a condenação, pois não há qualquer dúvida de que a intenção dos acusados era a de entregar a droga apreendida ao consumo de terceiros até porque, a quantidade de entorpecente apreendido (25 tijolos de maconha) é incompatível com o uso momentâneo. E aqui, ressalte-se que a versão por eles dada é absolutamente fantasiosa, não merecendo o mínimo de credibilidade, vez que pueril e absolutamente divorciada do conjunto probatório. Ora, não é minimamente crível que

os dois não tenham questionado o corréu Vinicius sobre uma caixa térmica pesando mais de 13 Kg, até porque, sem sombra de dúvida, foi necessária a ajuda de todos para conseguir colocá-la no interior do veículo.

Já a confissão parcial do corréu Vinicius admitindo que praticou sozinho o tráfico de drogas revela, tão somente, mais uma tentativa inexitosa de livrar os réus Francisco e Nestor das imputações de tráfico, bem como reduzir significativamente sua pena almejando o reconhecimento do privilégio previsto no § 4º do art 33. Nesse contexto, as versões dos réus, além de inconsistente e implausível de per si, permaneceram de todo isolada no contexto probatório, já que nada produziram, em absoluto, que ao menos desse algum lastro às suas informações, enquanto os depoimentos reproduzidos sob o contraditório encerraram-se convergentes e coesos à confirmação do fato imputado, não se percebendo qualquer mínima evidência que fosse acerca de uma falsa incriminação.

Neste diapasão, os depoimentos dos policiais foram absolutamente coerentes e bastaram à comprovação dos fatos, por não haver na hipótese qualquer contradição ou indício de que tenham faltado com a verdade para incriminar falsamente a ré. Assim, sua negativa de autoria nada mais revela do que o intuito de não produzir prova contra si mesmo, o que é plenamente lícito, mas insuficiente para desfigurar a tese acusatória que vem amparada pelo depoimento dos policiais e prova da materialidade.

Por outro lado, os policiais narraram a dinâmica dos fatos de forma coerente e linear, descrevendo a ocorrência de forma idêntica ao quanto narrado em fase policial, sendo certo que os depoimentos dos agentes da Lei, sejam civis, militares, ou mesmo guardas municipais, têm valor igual aos depoimentos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros da polícia, sendo totalmente descabido eventual preconceito acerca de seus testemunhos.

E também não se vislumbra ilegalidade ou inconstitucionalidade no depoimento de tais agentes, pois, na condição de testemunhas, como qualquer outra pessoa (CPP, art. 202), prestam compromisso, nos termos da lei, e estão sujeitos às penas por falso testemunho que, como visto, não tinham razão para incriminá-la, graciosamente, tanto que foram ouvidos em audiência e não foram contraditados no momento oportuno (CPP, art. 214). Até mesmo porque, in casu, inexistem motivos para desqualificar os depoimentos dos milicianos, pois não há provas ou indícios nos autos indicando que estes pretendiam incriminar injustamente a ré ou em faltarem com a verdade. Por tais razões, seus testemunhos merecem normal credibilidade e valor probatório. Neste sentido:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846) (g.n.)

Por derradeiro, observo que para a caracterização do crime em questão, não se exige a venda propriamente dita do entorpecente, pois o tipo penal inserto no artigo 33 da lei antidrogas fez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aqueles de "ter em depósito" "transportar" e "trazer consigo". Dessa maneira, basta a conduta de trazer consigo a droga, desde que evidenciada a finalidade de entrega a terceiro, para que o crime em questão reste caracterizado. E, no caso, essa finalidade está bem evidenciada, diga-se mais uma vez, pela expressiva quantidade de droga apreendida (25 tijolos de maconha pesando mais de 13 kg), tornando-se incabível falar em desclassificação para o crime de posse de drogas. Confira-se: "Anoto, ainda, que para configuração do crime do artigo 33, da Lei de Drogas imputado aos réus, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando que os agentes tragam consigo, tenham em depósito ou guardem a substância entorpecente, não se exigindo a tradição, para consumação do delito (RJTJSP vol. 97, página 512)"

(9174718-08.2009.8.26.0000, Rel. Marco Antonio Marques Maia, 6ª Câmara de Direito Criminal, 17/09/2009)" (grifo nosso)

...

"O crime de tráfico de entorpecente é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT 776/663) (grifo nosso)

De outra feita, a defesa não explicou e não logrou refutar as assertivas minuciosas dos depoentes e não arrolou testemunhas que amparassem suas ressalvas. Não indicou motivos concretos e plausíveis para falsa incriminação. Não demonstrou vício no flagrante e no resultado da persecução. Assim, o contexto fático revela, de maneira indubitosa, que a ré praticava o comércio de entorpecente, sendo de rigor a condenação.

Diante do exposto, por esses fundamentos e mais o que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO os réus FRANCISCO HERNANDES NETO, NESTOR FELIPE VALMOR STRINGHETTA e VINICIUS SEABRA DUARTE, todos já qualificados nos autos, como incursos nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 c.c. art. 29 "caput" do Código Penal. Resta dosar a pena pelo critério trifásico adotado pelo Código Penal.

Em relação ao réu: FRANCISCO HERNANDES NETO:

Atento aos ditames do artigo 42 da Lei de Drogas, bem como aos elementos preconizados pelo artigo 59 do Código Penal e à sua primariedade (F.A. e certidões a fls. 238 e 463/464), fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica do réu (CP, arts. 49 e 60). Na segunda fase, ausentes quaisquer outras circunstâncias agravantes e/ou atenuantes. Na terceira fase, entendo que se faz necessário o reconhecimento da diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, pois o réu é primário e não há nos autos notícias de que participe ou integra associação e/ou organização criminosa. Porém, diante da quantidade de droga apreendida (254 tijolos de maconha pesando mais de 13 Kg), faço a diminuição de 1/4 (um quarto). Não estão presentes mais causas de aumento ou de diminuição da pena. Portanto, fixo em definitivo a pena a cumprir de 03 (TRÊS) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO e PAGAMENTO DE 375 (TREZENTOS E SETENTA E CINCO) DIAS-MULTA, com o dia unitário no piso mínimo legal.

Em relação ao réu VINICIUS SEABRA DUARTE:

Atento aos ditames do artigo 42 da Lei de Drogas, bem como aos elementos preconizados pelo artigo 59 do Código Penal e à sua primariedade (F.A. e certidões a fls. 239/240 e 468/469), fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica do réu (CP, arts. 49 e 60). Na segunda fase, ausentes quaisquer outras circunstâncias agravantes e/ou atenuantes. Na terceira fase, entendo que se faz necessário o reconhecimento da diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, pois o réu é primário e não há nos autos notícias de que participe ou integra associação e/ou organização criminosa. Porém, diante da quantidade de droga apreendida (254 tijolos de maconha pesando mais de 13 Kg), faço a diminuição de 1/4 (um quarto). Não estão presentes mais causas de aumento ou de diminuição da pena. Portanto, fixo em definitivo a pena a cumprir de 03 (TRÊS) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO e PAGAMENTO DE 375 (TREZENTOS E SETENTA E CINCO) DIAS-MULTA, com o dia unitário no piso mínimo legal.

Pese contrário ao entendimento deste Magistrado, necessário apontar que o regime inicial deverá ser o ABERTO para os réus Francisco e Vinicius, conforme recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exarado no bojo do HC n. 596603-SP,

no qual houve determinação para imposição de regime inicial aberto para cumprimento de pena, inclusive em relação a fatos futuros, na hipótese de condenação por tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, §2º, do Código Penal. Confira-se (...) Aos condenados que atualmente cumprem pena e aos que vierem a ser sancionados por prática do crime de tráfico privilegiado, determinar que não se imponha – devendo haver pronta correção aos já sentenciados – o regime inicial fechado de cumprimento da pena. (STJ - HC: 596603 SP 2020/0170612-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 04/08/2020).

Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal - HC 118.533 – reconheceu que o delito em questão não é mais hediondo, entendo viável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Desta forma, faço a substituição da pena privativa de liberdade anteriormente fixada por duas restritivas de direitos. Assim sendo, observado o disposto pelo artigo 44, parágrafo 2º, 2ª parte e na forma dos artigos 45, parágrafo 1º e 46, todos do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam, a de Prestações de Serviços à Comunidade e de Prestação Pecuniária, por se revelarem as mais adequadas ao caso, sendo aquela consistente em tarefas gratuitas a serem desenvolvidas, pelo prazo da condenação, junto a entidade determinada pelo juízo da execução, devendo ser cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, que será distribuída e fiscalizada, de modo a não prejudicar a jornada de trabalho do condenado, sem prejuízo da multa já fixada e a prestação pecuniária no valor de um terço do salário mínimo nacional da época da infração penal, sendo destinada para entidade beneficente também indicada pelo juízo das execuções penais.

De acordo com o artigo 387, parágrafo único do CPP, inalterados os requisitos e não existindo prisão provisória decretada, os réus Francisco e Nestor poderão apelar em liberdade. Ausentes os requisitos da prisão preventiva, REVOGO a prisão preventiva decretada a fls. 122/125. Expeçam-se alvará de soltura.

Ao Juízo da Execução, após o trânsito em julgado desta decisão, caberá fiscalizar a entidade beneficiada com a prestação de serviços, a qual deverá ser comunicada a respeito, através de seu Representante, com remessa de cópia da presente sentença, incumbindo-lhe encaminhar mensalmente relatório circunstanciado, bem como a qualquer tempo, comunicar sobre a ausência ou falta disciplinar da condenada, consoante disposto pelo artigo 150 da Lei nº 7.210/84. Deverá, ainda, ser cientificado que a condenada é facultada cumprir a pena substitutiva em menor tempo (artigo 55, do Código Penal), sendo que, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada ou restante.

Quanto ao réu NESTOR FELIPE VALMOR STRINGHETTA:

Em observância ao artigo 42 da Lei de Drogas, bem como aos elementos preconizados pelo artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu, embora ostente antecedentes criminais (F.A. e certidões a fls. 235/237 e 465/467), a pena-base deve ser fixada em seu patamar mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica do réu (CP, arts. 49 e 60). Na segunda fase de dosimetria, embora presente a agravante da reincidência (fls. 235/237), o réu confessou a prática delitiva. Assim, faço a compensação e mantenho a pena no patamar anterior fixado, nos termos da Súmula/STJ, nº 545: “Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal”. Não estão presentes outras agravantes ou atenuantes. Por fim, na terceira fase, entendo que inexistem causas de aumento ou de diminuição da pena. Não incide a benesse prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, pois o réu não preenche todos os predicados legalmente previstos, precipuamente a reincidência e quantidade de entorpecente apreendido, o que revela dedicação às práticas delitivas. E nem se alegue possível bis in idem relativo ao aumento da pena pela reincidência e a não aplicação do aludido redutor, uma vez que este deixou de incidir também em virtude da dedicação às práticas delitivas, tudo em fases distintas da dosimetria. Confira-se: “A valoração da reincidência na segunda etapa da dosimetria, como circunstância agravante, não é incompatível com a sua

utilização, na terceira fase, para afastar a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porquanto o referido instituto jurídico é sopesado com finalidades distintas em cada fase de fixação da pena, justamente para se alcançar a justa e correta reprimenda necessária para a reprovação e prevenção do delito perpetrado. Precedentes" (HC 214069/SP - Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ - Sexta Turma - DJe 29/11/2013). Desta forma, fixo em definitivo a pena a cumprir de 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA COM O DIA UNITÁRIO NO PISO MÍNIMO LEGAL.

A pena imposta ao réu deverá ter seu início de cumprimento em regime FECHADO. Apesar de o STF já ter decidido, em sede de controle difuso, pela inconstitucionalidade da regra que determina a obrigatoriedade de adoção de regime inicial fechado para os crimes hediondos e equiparados (Lei 8.072/90, art. 2º, §1º), o citado precedente não concluiu, por outro lado, pela imposição indiscriminada de regime mais brando para o cumprimento inicial da pena em tais delitos. Ao contrário. Ainda que, de fato, não possa a lei vedar, aprioristicamente, a adoção de um regime inicial diverso do fechado, mesmo para os crimes hediondos e equiparados, o STF permitiu a adoção de regime inicial mais severo quando presentes elementos concretos e individualizados, aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do § 3º do art. 33, c/c o art. 59 do Código Penal (cf. HC 111.840, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/12/2013). O caso dos autos, no qual se constatou a prática de tráfico de considerável quantidade de entorpecente, demanda a adoção de regime prisional mais severo, sob pena de se produzir, como efeito colateral de um arrefecimento despropositado da reprimenda estatal, uma sensação de impunidade àqueles que demonstram desprezo à manutenção da ordem pública.

É importante não perder de vista que a consideração do tempo de prisão provisória do réu não altera o panorama do regime inicial da pena aplicada. Assim, deixo de aplicar o disposto no § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, pois como bem indica Guilherme de Souza Nucci, "O disposto no §2º do artigo 387 do Código de Processo Penal, permite que o julgador promova o desconto pertinente à detração ao escolher o regime inicial do réu no caso de condenação. Não significa de modo algum que o magistrado deve sempre conceder o regime inicial mais brando, pois se pode considerar como adequado regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 59 do Código Penal, indicado pelo art. 33, § 3º. Afinal, somente o juiz da execução penal possui o quadro completo das condenações daquele réu, do seu comportamento carcerário, e do seu merecimento" ("Código de Processo Penal Comentado", 13ª edição, Editora Forense, páginas 805 e 806). Desta forma, melhor que a questão seja analisada pelo Juízo de Execuções Criminais, que certamente disporá de elementos mais substanciais para decidi-la.

Inviável a substituição por pena restritiva de direitos, seja pelo fato de estarem ausentes os requisitos previstos nos artigos 44, III, e 77, II, ambos do Código Penal, seja porque o art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 estabelece que a reprimenda por crime de tráfico de drogas deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, seja, finalmente, porque o art. 44, caput, da Lei nº 11.343/2006, são expressos ao proibir referido benefício. Filio-me ao entendimento que sustenta a constitucionalidade de tais dispositivos, pelas seguintes razões, algumas delas retiradas da Arguição de Inconstitucionalidade no HC 120.353-SP, julgada em 04.11.2009 pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, Rel. originário Min. Og Fernandes, Rel. para acórdão Min. Ari Pargendler: i) o art. 5º, inciso XLVI, da CF/88, determina que a lei regulará a individualização da pena; ii) o art. 5º, inciso XLIII, da CF/88, estabelece que a lei deverá dispensar tratamento mais gravoso ao crime em questão, destacando também a importância da repressão a esse delito no art. 5º, inciso LI, o qual autoriza a extradição de brasileiro naturalizado comprovadamente envolvido com tráfico de drogas; iii) é perfeitamente possível que o legislador ordinário proíba a substituição da pena por restritiva de direitos, tanto que o art. 44, do CP, veda o benefício para todos os crimes praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa ou com pena superior a 04 anos, ou, ainda, no caso de ser o agente reincidente em crime doloso; iv) o Brasil assinou tratados internacionais se comprometendo a combater o tráfico de drogas; v)

o crime de tráfico de drogas, além de ser equiparado a hediondo e ser a principal causa de inúmeros outros delitos patrimoniais, gera efeitos nefastos para a sociedade e para as famílias de bem, de modo que a concessão do benefício, além de ser, no meu entender, incompatível com a sua gravidade, não se mostraria suficiente para a prevenção ou reprovação do delito (CP, art. 59, in fine), gerando ofensa ao disposto no art. 44, III, do CP, além de verdadeira sensação de impunidade nesta interiorana cidade de Avaré.

Deixo de reconhecer o direito do réu Nestor apelar em liberdade, em observância ao artigo 312 do CPP c.c. artigo 2º, § 3º da Lei nº 8.072/90, pois a gravidade do delito, que vem se alastrando de forma avassaladora também nas pequenas cidades, torna evidente a necessidade da prisão para se garantir a ordem pública. Ademais, o réu foi preso preventivamente e permaneceu recolhido por todo o processo e não seria razoável, agora que foi condenado, ser colocado em liberdade, ainda que diante do regime imposto pela lei e do fato de ter praticado conduta de extrema gravidade, que deve ser exemplarmente punido. Recomende-se.

Conforme art. 63 da Lei nº 11.343/06 c/c art. 91 do CP, decreto o perdimento de tudo quanto apreendido neste processo. Não tendo havido controvérsia, no curso do processo, sobre a natureza e a quantidade da substância entorpecente ou sobre a regularidade do laudo respectivo, fica determinado, desde já, sua destruição por incineração, na forma da legislação vigente (Lei n. 11.343/06, arts. 33, §§ 1º e 2º, e 58, §1º), no prazo máximo de 30 (trinta) dias, preservando-se fração suficiente para eventual contraprova. Comunique-se à autoridade de polícia judiciária competente, caso isso ainda não tenha sido providenciado.

Registre-se, desde logo, que, em caso de recebimento de eventual recurso de apelação interposto contra a presente, deverá ser expedida a competente guia de execução provisória em nome do réu/condenado recorrente, nos termos do que dispõe o art. 9 da Resolução nº 113/2010 – CNJ, para que possa, quando for o caso, obter os benefícios previstos na LEP (sumula do STF, Enunciado nº 716).

Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente, adotem-se as seguintes providências: (a) expeça-se guia de execução (definitiva, se o caso) do condenado; (b) proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, em conformidade com o disposto no artigo 686, do Código de Processo Penal; (c) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando sua condenação, com a devida identificação dele, acompanhada de fotocópia desta decisão, para cumprimento do disposto no art. 15, III, da Constituição da República c/c o art. 71, §2º, do Código Eleitoral; (d) oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias; (e) efetuem-se as averbações de praxe (NSCGJ, Cap. V, itens 22, d, e 23). Custas processuais nos termos da lei. P.I.C.

Avaré, 15 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA